

1503546-69.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503546-69.2019.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503546-69.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 7561/2019 - DEL.POL.GUARUJA, 2312538/2019 - DEL.POL.GUARUJA, 8221009 - DEL.POL.GUARUJA, 2312538 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO CARLOS LOPES JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

João Carlos Lopes Júnior, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 25 de outubro de 2019, por volta das 20:20 horas, na Avenida Presidente Vargas, altura do nº 363, Parque Estuário, nesta cidade e Comarca de Guarujá, trazia consigo, para o consumo de terceiros, drogas consistentes em 99 (noventa e nove) porções de crack, derivado da cocaína, e em 50 (cinquenta) porções de cocaína, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, o auto de constatação preliminar de fls. 08/09 e as fotografias de fls. 18/20, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi juntado aos autos o laudo de exame químico toxicológico realizado nas drogas apreendidas (fls. 123/125).

O réu foi notificado (fls. 117) e apresentou defesa prévia (fls. 139), que não foi acolhida e a denúncia foi recebida (fls. 144/145).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação (fls. 195), uma testemunha de defesa (fls. 196) e o réu interrogado (fls. 196). Foi declarada encerrada a instrução e pelas partes não foram requeridas diligências (fls. 197).

O representante do Ministério Público, nos memoriais, requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, argumentando que a autoria e a materialidade restaram provadas durante a instrução criminal (fls. 197/203).

Nos memoriais, a defesa do réu requereu a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de condenação pelo crime de tráfico de drogas, requereu a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 220/233).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/03, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, pelo auto de constatação preliminar de fls. 08/09, pelas fotografias de fls. 18/20, pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 123/125, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria do réu também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Interrogado em juízo, o réu alegou ser usuário drogas e disse que no dia dos fatos vendia as drogas para quitar dívida com traficante no valor de R\$150,00. Alegou que caso não pagasse a dívida o traficante o ameaçou dizendo que quebraria os dois braços e as duas mãos do interrogando. Não havia feito nenhuma venda quando foi abordado. Não conhecia os policiais (fls. 196).

E a confissão do réu, como seria de rigor, restou corroborada pelas provas produzidas nos autos, que demonstraram a autoria delitiva e não foi apresentada situação a excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

O policial militar Hilios Antonio de Souza Brito, no seu depoimento judicial, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento pelo Guarujá quando visualizou um indivíduo em pé na calçada. Abordaram o indivíduo e durante revista pessoal localizaram uma sacola de cor verde no interior das vestes dele. Dentro da sacola havia algumas porções de cocaína e algumas pedras de crack, bem como uma nota de dois reais. O local é conhecido pelo tráfico de drogas. Indagado, o réu disse que estava vendendo drogas para receber cerca de cento e cinquenta reais por um turno de oito horas de serviço. Não conhecia o réu anteriormente. O réu disse que estava traficando fazia pouco tempo. O local é frequentado por usuários de drogas (fls. 195).

Paulo César Rodrigues dos Santos Nawoe, policial militar, em juízo, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento pela Avenida Presidente Vargas quando visualizou o réu em um local conhecido pelo tráfico de drogas. Ao ver a viatura o réu demonstrou certo nervosismo. Abordaram o réu e localizaram uma sacola plástica de cor verde com ele. Dentro da sacola havia noventa e nove pedras de crack, cinquenta e duas trouxas de cocaína e uma nota de dois reais. Indagado, o réu confessou a prática do tráfico e disse que recebia cento e cinquenta reais por período. O réu disse que traficava no local fazia pouco tempo. Pelo que se recorda ninguém se aproximou do local dos fatos no momento da abordagem, mas existiam algumas pessoas no local, pois se tratava de um comércio. Não conhecia o réu anteriormente (fls. 195).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de

delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição.

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, [...]". (STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, Dje 08/04/2019).

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, Dje. 30/10/2018).

Ora, diante dos depoimentos dos policiais e da prova material apreendida, sem dúvida o réu trazia consigo os entorpecentes apreendidos e os entorpecentes eram destinados para o consumo de terceiros, ou seja, para a venda.

Tem-se que diante do contexto fático em que ocorreram os fatos, do teor dos depoimentos dos policiais, que narraram de forma segura e harmônica a conduta do réu, diante da quantidade dos entorpecentes encontrados com o réu, incompatíveis com o uso, bem como diante da confissão do réu, restou comprovada a conduta típica do réu narrada na inicial acusatória.

Ressalto que o depoimento da testemunha de defesa não foi capaz de afastar a conduta típica praticada pelo réu.

Vanessa Evangelista dos Santos Souza, em juízo, disse que conhece o réu há mais de vinte anos porque o réu trabalha com música e já fez alguns trabalhos na escola em que era diretora. Não presenciou a prisão do réu. O réu é um excelente músico, mas as drogas o atrapalharam. O réu era usuário de drogas. O réu é pobre e vive através de ajuda de algumas pessoas (fls. 196).

Como se vê, a testemunha de defesa não presenciou os fatos e apenas confirmou que o réu é usuário de drogas.

Portanto, diante das provas produzidas, a autoria do delito é indiscutível. É certo que o réu trazia consigo os entorpecentes e os entorpecentes eram destinados para o consumo de terceiros, ou seja, para a venda, ante a conduta do réu narrada pelos policiais, destacando-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

E ainda, mesmo que o réu seja usuário de drogas, tal fato não afasta, necessariamente, a prática do delito de tráfico, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de substâncias entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.

A propósito:

"(...) Ademais, a condição de usuário de drogas não exclui a de traficante, sendo infelizmente comum a mercancia realizada por usuários com o intuito de financiar seu vício (...)" (TJSP, Apelação nº 0000136-06.2016.8.26.0626, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Damião Cogan, julgado em 10/05/2019).

Por fim, o crime de tráfico imputado ao réu restou consumado, restando evidenciado que os entorpecentes apreendidos com o réu eram destinados à venda e ao consumo de terceiros.

Definida a conduta do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, fixo a pena-base no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, a pena permanece inalterada. Destaco que a atenuante da confissão não pode levar a pena-base aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, verifico que o acusado preenche os requisitos legais previstos no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois é primário e não existem indícios de que integra organização criminosa. Assim, preenchidos os requisitos legais, considerando a quantidade dos entorpecentes (21,1 gramas de crack e 8,9 gramas de cocaína - fls. 123/125), aplico a causa de diminuição e reduzo a reprimenda em 2/3, perfazendo o total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em relação ao regime prisional, considerando que o pleno do STF decidiu recentemente que "O chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) não deve ser considerado crime de natureza hedionda." (HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016), que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal, modifico entendimento anterior e passo a entender que o crime de tráfico de drogas privilegiado não é crime equiparado a hediondo, de forma que o regime será fixado de acordo com o disposto nos artigos 33 e 59 do Código Penal.

Neste sentido a jurisprudência:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida" (Pleno, HC nº 118.533, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016 grifos da reprodução).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ACUSADO SEM OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA ESTABELECIDNA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO DEFERIDO, POIS PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. - Não há como manter a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, que afastou a figura do tráfico privilegiado sob a tese de que o paciente dedica-se às atividades criminosas pelo fato de não exercer atividade lícita, pois estava desempregado à época dos fatos. Ademais, a quantidade da droga apreendida - 2,71g de cocaína -, apesar de nociva, não foi tão elevada a ponto de indicar, juntamente com as circunstâncias em que ocorreu o delito, a dedicação do acusado às atividades criminosas. - O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela

Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Hipótese em que o paciente é primário, condenado à pena não superior a 4 anos de reclusão, com análise favorável das circunstâncias judiciais, razão pela qual faz jus ao regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea c, do CP. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer a sentença que fixou as penas em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 221 dias-multa e modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. (HC 336.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). E sendo assim, analisando os autos, tendo sido a reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Cumprе destacar que, apesar da Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" presente no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não seria o caso de substituição da pena, pois não se mostra medida suficiente e adequada ao presente caso.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra João Carlos Lopes Júnior para CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O acusado poderá apelar em liberdade.

Em relação aos entorpecentes apreendidos, cumpra-se a decisão de fls.51, providenciando-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, reservando-se contraprova.

Após o trânsito em julgado oficie-se à autoridade policial para providenciar a incineração da porção reservada para contraprova.

Após o trânsito em julgado, determino o perdimento do dinheiro (R\$ 2,00) apreendido, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, tendo em vista que as provas produzidas nos autos demonstraram se tratar de produto de tráfico ilícito de entorpecente. Providencie-se o necessário.

Custas na forma da lei.

Guaruja, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA